



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	תובעות	שהם רינה, ת.ז. XXXXX
2		פולמן ונדה, ת.ז. XXXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד יוסף ישורון ואח'
פל-ים 5 חיפה, 31021
דוא"ל: shahar@j-law.co.il
טל': 04-8556633 פקס: 04-8556634

1	נתבעים	נגד	וורבנר ניר, ת.ז. XXXXX
2			וורבנר פטר, ת.ז. XXXXX
3			בן ארי משה, ת.ז. XXXXX
4			בן ארי אירית, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד צבי הרשקוביץ
פלי"ם 2, חיפה
טל': 04-8665999, פקס: 04-8663178
דוא"ל: zvi@zh-law.co.il

פסק דין

- עניינה של התביעה בשאלה האם יש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות בבית מושא ההליך בהתאם להיתר בנייה שקיבלו, חרף התנגדות התובעות שהן בעלים של שתי דירות אחרות באותו הבית.
- הבית מושא ההליך מורכב משני מבנים. האחד, מכיל שתי דירות, והשני, מכיל 4 דירות: שתיים בקומת קרקע ושתיים בקומה א'. הבית מזוהה כחלקה 28 בגוש 10786 ונמצא ברח' ויתקין 23, חיפה (להלן: "הבית/הבית המשותף"). הבית נרשם כבית משותף ביום 11.4.54. תובעת 1 היא בעלים של דירה בקומת הקרקע במבנה מס' 2, ותובעת 2 היא בעלים של דירה בקומה א' במבנה מס' 2. הנתבעים 1-2 הם הבעלים של דירה בקומה א' במבנה מס' 2 והנתבעים 3-4 הם הבעלים של דירה בקומת הקרקע במבנה מס' 2 (להלן: "מבנה מס' 2"). בעליהם של הדירות במבנה מס' 1 אינם צד להליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה נתנה החלטה המאשרת את בקשת הנתבעים לתוספות בנייה (בקשה מס' 50365515) במבנה מס' 2, הוגשה תביעה זו. במסגרת הבקשה להיתר בנייה ביקשו הנתבעים להוסיף חדרי מגורים בדירתם על חשבון החצר המשותפת, לבנות מדרגות חיצוניות המובילות לחצר, לבנות מחסן בחצר, לבנות תוספת בנייה על הגג המשותף תוך פריצת פתח בגג, להקים חדר יציאה על הגג ופרגולה לשימוש הפרטי, להקים אגף ממ"דים ועוד.

4. התובעות הגישו ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וביום 25.12.19 נדחה הערר תוך שוועדת הערר קבעה כי בפן הקונסטרוקטיבי והתכנוני יגישו הנתבעים אישור קונסטרוקטור אליו יהיו רשאים התובעים להתייחס בכתב, וככל שתוצגנה חוות דעת סותרות תמנה הוועדה המקומית קונסטרוקטור מטעמה אשר יבחן את מידת ההשפעה של תוספות הבנייה על המבנה, ואת הצורך בחיזוק המבנה. מבחינה קניינית, נמנעה ועדת הערר מהכרעה והמליצה לתובעות לפנות לערכאות המתאימות לכך.

תמצית טענות התביעה –

5. המהנדס שמונה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מר שולץ, התייחס לתכנית הנתבעים ומתח ביקורת קשה על הנתונים כפי שנמסרו על ידי המהנדס מטעמם. במענה לחוות דעת המהנדס שולץ, הגישו התובעות חוות דעת משלימה אשר על בסיסה, ועל בסיס עמדות הצדדים, התקיים דיון חוזר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה בו נקבע כי תאושר הבקשה בתנאים הבאים: שינוי מיקום אגף הממ"דים המוצע; לא תבוצע הריסה של קיר נושא עומס חיצוני במעטפת המבנה המקורית; ביצוע תפר עובר בתוך חללי מגורים בפיקוח צמוד.

6. לבית מושא ההליך נרשם הסכם מיום 22.4.54 המהווה תקנון מוסכם (להלן: "התקנון המוסכם") הקובע בין היתר, כי שטח הגינה המסומן בצבע כחול משמש בתור גינה עבור בעלי הדירות 3-6 (הם הצדדים להליך), ואסור להשתמש בשטח זה לכל מטרה אחרת. עוד נקבע בהסכם כי "לא ייעשה כל שינוי שהוא בצורת השימוש בחלקי הגינה של הבית המשותף הנ"ל כפי שנקבעו לעיל בלתי אם ע"י הסכם בכתב אשר כל בעלי הדירות יחתמו עליו ויירשם כחוק במשרד ספרי האחוזה". לאור הוראת התקנון המוסכם לא ניתן לבצע עבודות בנייה בגינה או לשנות את ייעודה ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ומשכך, לא ניתן לקדם הליכי ההיתר לבנייה בשטח הגינה.

7. אין לאשר לנתבעים את הבנייה מהטעם שהיא עומדת בסתירה להוראת התקנון המוסכם, וכן תפגע באופן קשה בזכויות התובעות.

8. לאור התנגדות התובעות, המהוות בעלים של שתי דירות מתוך ארבע במבנה 2, הבנייה שמבקשות הנתבעות לבצע נעדרת הסכמה בשיעור הנדרש בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). יתרה מכך, הבנייה כוללת השתלטות על חלקים ברכוש המשותף, גידור חלקים מהגינה המשותפת, הקמת מחסן בשטח רגלי הממ"ד והקמת מדרגות חיצוניות, לרכיבי בנייה אלו נדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית.

9. מבנה 2 הוא מועמד טבעי לחיזוק בהתאם לתמ"א 38 הן מהטעם שנבנה בשנות ה-50, הן בשל מיעוט בעלי הדירות שבו, והן בשל גודל החלקה (1,311 מ"ר). הבנייה מושא ההליך עלולה לסכל קבלת תוספת זכויות בנייה בבנייה לפי תמ"א 38, הן מהטעם שחיזוקו יסכל אפשרות כאמור, והן מהטעם שבנייה על הגג מאיינת שימוש בגג לבניית דירות נוספות בתמורה לחיזוקו במסגרת תמ"א 38 ומשכך תפגע בזכויות התובעות.

תמצית טענות ההגנה –

10. על החלקה מושא ההליך קיימים שני מבנים ובסה"כ שש דירות המהווים יחדיו בית משותף אחד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. הנתבעים מבקשים להרחיב את דירותיהם, לרבות באמצעות בניית ממ"ד לכל אחת מהדירות באופן שמנצל אך ורק את חלקם היחסי של דירותיהם באחוזי הבנייה הניתנים לניצול.

12. שני בעלי הדירות במבנה 1 אינם מתנגדים לבנייה מושא ההליך. גם התובעות מעולם לא אמרו לנתבעים כי הן מתנגדות לבנייה המבוקשת. נהפוך הוא, התובעות הבהירו לנתבעים כי בכפוף לשמירה על חלקן היחסי בזכויות הבנייה, הימנעות מיצירת מפגע תכנוני והבטחה כי הבנייה לא תגרום לפגיעה בהן וברכושן, הן לא תתנגדנה לבנייה. בהסתמך על עמדתן זו פעלו הנתבעים משך שנים בתכנון תוספות הבנייה, תוך שהם משקיעים זמן והון רב בהליכים תכנוניים שונים ובמגעים עם התובעות ובא כוחן, והכול במטרה להפסיק את דעתן של התובעות ולהבטיח את זכויותיהן היחסיות בחלקה. כפועל יוצא, הנתבעים והאדריכל מטעמם תכננו את תוספות הבנייה המבוקשות תוך שהם משנים ועורכים שינויים בתוכניותיהם בהתאם לגחמות ולהנחיות התובעות. לצורך כך קיימו הצדדים עשרות שיחות ופגישות לתיאום ציפיות, זאת בשים לב לעובדה שהנתבעות מעולם לא הביעו התנגדות עקרונית לבנייה, ומתוך הבנה כי הן תאפשרנה את הבנייה ככל שזו לא תפגע ברכושן ובזכויותיהן. נוכח עמדתן זו של התובעות שינו הנתבעים מצבם לרעה באופן שהשקיעו עשרות אלפי שקלים בהליכי תכנון, הקדישו 5 שנים בניסיון ליישם את רצון התובעות.

13. ביום 28.4.17 העבירו התובעות לנתבעים טיוטת הסכם, אשר מעיון בו ניתן להיווכח כי עסקינן בהסכם דרקוני שאמור היה לגרום לנתבעים לעלויות כספיות עודפות בהיקפים גדולים מאוד. הנתבעים היו מוכנים לקבל את מלוא הוראותיו למעט שתיים שהן: מתן "שיק פתוח" בצורה הרחבה והגורפת ביותר לכל בנייה שהיא שהתובעות תחפצנה לבצע בעתיד, והעמדת ערבות בנקאית על סך 500,000 ₪ החל מיום חתימת ההסכם ועד לשנה לאחר סיום הבנייה להבטחת מילוי התחייבויות הנתבעים. עסקינן בהוראות בלתי סבירות בעליל שנועדו בחוסר תום לב מוחלט להכשיל את אפשרות הנתבעים לבצע את הבנייה.

14. לאור הפסיקה בנושא תום הלב, המונעת מבעל דירה לגרום "נזק או אי נוחות לאחר" אין לאפשר לתובעות למנוע את הבנייה מושא ההליך.

ההליכים בתיק -

15. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. התקיים דיון הוכחות ביום 21.3.23, במהלכו העיד מטעם התביעה ארי פולמן, בנה של תובעת 2, ומטעם ההגנה העיד נתבע מס' 1.

16. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה -

17. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולאסור על הבניה מושא ההליך, הכל כפי שיפורט להלן.

משמעות הצמדתה של החצר לדירות הצדדים להליך-

18. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע את הדרך להוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה בבית כדלהלן:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". (הדגשה שלי י"ל)

19. סעיף 59(א) לחוק המקרקעין מגדיר "בית מורכב" כדלהלן:

"מקום שבו בית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף".

20. עיון במסמכי רישום הבית המשותף מעלה כי עסקינן בבית המורכב משני מבנים כאשר במבנה אחד שתי דירות, ובשני, הוא המבנה מושא ההליך, ארבע דירות (להלן: "המבנה השני").

21. סעיף 59 לחוק המקרקעין מבחין בין שני סוגי הסדרים לבית מורכב. הראשון, הוא בית מורכב בו חלקים מסוימים מן הרכוש המשותף הם בשימוש חלק מוגדר בלבד מבעלי הדירות ועל כן הוצמד לאותן דירות. השני, הוא בית מורכב שהרכוש המשותף שבו לא הוצמד לדירות אותן הוא משמש, אך נקבע בתקנון המוסכם שנרשם לבית כי החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף יחול על בעלי הדירות אותם הוא משמש, ראו ספרו של פרופ' ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, חלק 2 עמ' 400 ואילך, וראו רע"א 18/2575 עקבסון נ' לוין (נבו, 25.3.19) שם נקבע, בין היתר כי:

"במישור הקנייני הפורמאלי בבית מורכב "מוצמד" אין לבעלי הדירות בחלק אחד של הבית המורכב זכות בעלות ברכוש המשותף המוצמד לחלק האחר של הבית המורכב, בעוד שבבית מורכב "לא מוצמד" לכלל בעלי הדירות יש בעלות פורמאלית גם באותו חלק מהרכוש המשותף שהופרד מהם במישור הניהולי (ראו: ע"א 56911/50 קליין נ' שרון, פסקה 33 לפסק דינה של השופטת (כתוארה אז) מ' נאור (72.8.9002); ויסמן, בעמ' 404)".

22. עיון בתקנון המוסכם שנרשם לבית מעלה כי הבית מהווה בית משותף מורכב מהסוג הראשון כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, לאחר ששטח הגינה שסומנה בתשריט רישום הבית המשותף בצבע כחול הוצמד לדירות במבנה השני.

23. בסוג ההסדר הראשון חדלה החצר שהוצמדה לדירות מושא ההליך להיות חלק מן הרכוש המשותף הכללי, והיא הופכת להיות לרכוש משותף של בעלי הדירות שאליהם הוצמדה. פרופ' ויסמן העלה בספרו את השאלה האם הכוונה לכך שאותה חצר היא בבעלות משותפת רגילה או שמא מדובר בתת סוג של "רכוש משותף", כמשמעותו בפרק על בתים משותפים, והשיב כי לשיטתו אין להחיל על הרכוש המשותף החלקי, שהוצמד למספר דירות, את דיני הבעלות המשותפת אלא את דיני הרכוש המשותף שבפרק על בתים משותפים, ראו בספרו בעמ' 404.

24. כפי שציין, ובצדק, פרופ' ויסמן בספרו, נכון להחיל את הדין הכללי החל על רכוש משותף בבית משותף על רכוש משותף חלקי, וכפועל יוצא, דרך משל, לא תתאפשר תביעה לפירוק שיתוף ברכוש המשותף החלקי כמו גם ברכוש המשותף הכללי, ולא ניתן יהיה לבצע עסקה ברכוש המשותף החלקי ללא שהעסקה תחול גם על דירתו של אותו בעל דירה, זאת בדומה לקביעת סעיף 55(ב) לחוק המקרקעין המונע ביצוע עסקה ברכוש המשותף בנפרד מהדירה. ולענייננו, ברי כי הצדדים להליך אינם יכולים לבצע עסקה בחלקם היחסי בהצמדה המשותפת של החצר, ויש לראות בה רכוש משותף חלקי שלהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. עם זאת, ועל אף העובדה שהחצר עליה מבקשים הנתבעים לבנות מהווה רכוש משותף חלקי של הצדדים להליך, נקבע בפסיקה כי עדיין יש למנות את שיעור ההסכמות הנדרש לצורך הרחבת דירה בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין מקרב כלל בעלי הדירות בבית, וזאת משום שלצורך בניה בהתאם לסעיף, נדרש אמנם להוציא חלקים מהרכוש המשותף (הקרקע) לצורך בניה, אך במסגרת הבניה מנוצלים גם אחוזי בניה, אשר אין מחלוקת כי הללו מהווים רכוש משותף לכלל בעלי הדירות בבית בשני המבנים, ועל כן את ההסכמות לבניה יש למנות מקרב כל בעלי הדירות בבית בשני המבנים, ולא רק מקרב בעלי הדירות שהוצמד להם אותו רכוש משותף חלקי, כל עוד התקנון המוסכם שנרשם לבית לא קבע אחרת, ראו בעניין עש"א (חי') 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (נבו, 14.11.12) וכן ראו ע"א 2821/01, 2127/02, 2148/02 וילסקר נ' לויט (נבו, 08.08.02).

האם התקנון המוסכם שנרשם מחייב קבלת הסכמת כל בעלי הדירות בבית לבנייה –

26. התובעות טענו כי הוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית, אינן מאפשרות בניה בגינה ללא קבלת הסכמת כל בעלי הדירות במבנה מס' 2. אביא להלן את הוראות ההסכם מיום 22.4.54 שנרשם כתקנון המוסכם של הבית לשם בחינת הנושא:

"ב. השטח של החצר בבית המשותף הנ"ל המסומן בצבע כחול על התכנית הנ"ל ישמש בתור גינה עבור בעלי הדירות מס. 35/3, 35/4, 35/5 ו-35/6 במבנה השני, ואסור להשתמש בשטח הזה לכל מטרה אחרת.

ה. לא ייעשה כל שינוי שהוא בצורת השימוש בחלקי החצר של הבית המשותף הנ"ל כפי שנקבעו לעיל בלתי אם ע"י הסכם בכתב אשר כל בעלי הדירות יחתמו עליו והוא יירשם כחוק במשרד ספרי האחוזה.

ו. החלטת אסיפה כללית המכניסה איזה שינויים שהם בצורת השימוש בחלקי החצר כפי שנקבע לעיל, לא יהיה לה תוקף בלתי אם כל בעלי הדירות הסכימו להחלטה הנ"ל בכתב ורשמו אותה בתור הסכם נוסף או שינוי ההסדר במשרד ספרי האחוזה. " (הדגשה שלי י"ל).

27. שינויים ברכוש המשותף ושימושים ברכוש המשותף אין חד הם, ועל כן הפסיקה קבעה כי "שימוש סביר" ברכוש המשותף משמעו שימוש ברכוש המשותף ולא שינוי ברכוש המשותף, ראו לדוגמה ע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002).

28. במילון אבניאון (אינטרנטי) הוגדרה המילה "שימוש" כ:

"ניצול לתכלית מסוימת; תועלת מעשית ויום-יומית".

29. התובעות טענו כי לאור הוראות התקנון שנרשם לבית אין לאפשר לנתבעים בניה בשטח החצר ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית. דעתי אינה כדעת התובעות בעניין. מעיון בתקנון המוסכם עולה כי התקנון אסר על שימוש בגינה (שסומנה בתשריט בצבע כחול) לכל מטרה אחרת מלבד גינה. קרי, נקבע כי ניצול השטח יהיה לתכלית מסוימת – גינה, וכי זו התועלת המעשית היום יומית שתיעשה בשטח זה. לדידי, שטח החצר נועד לשמש כגינה ולא כחניות/ גן אירועים וכיוב', אך אין הדבר מונע ביצוע שינויים באותו רכוש משותף חלקי בדרך של ניצול זכויות קנייניות על גבי אותו שטח לצורך הרחבת דירות הבית, כל עוד קיימות הסכמות בשיעור שנקבע בחוק המקרקעין.

30. הנה כי כן, דעתי היא כי התקנון המוסכם שנרשם לא קבע כי לצורך הרחבת דירות הבית תידרש לבעלי הדירות בבית הסכמת כל בעלי הדירות, אלא קבע כי לצורך שינוי "בצורת השימוש" בחצר תידרש הסכמה כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. ביצוע עבודות בנייה ברכוש המשותף אינו מהווה שימוש ברכוש המשותף, כי אם ביצוע שינויים ברכוש המשותף, ועל כן, לביצוע הרחבה של דירות הבית על חשבון החצר נדרשת, לטעמי, הסכמה של בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בחוק המקרקעין לכל סוג בניה.

היקף ההסכמות הנדרש לבניית ממ"דים ותוספת בנייה לדירות הקיימות -

32. בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין נקבע שיעור ההסכמות הנדרש לצורך שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה. וכך נקבע בסעיף:

"71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

33. מהסעיף עולה כי לצורך הרחבת דירה נדרשת לנתבעים הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף, ולצורך הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי נדרשת לנתבעים הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית.

34. שני נתונים מצטברים אלו מהווים תנאים הכרחיים להשתכללות זכותו של בעל דירה לבנות ברכוש המשותף, ואלו הם: הזכות נתמכת ברוב של לפחות 75% מבעלי הדירות, אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת.

35. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף.

36. קנין הוכר בדין כזכות יסוד הראויה להגנה אך דיני הקניין של המשפט הפרטי, ובמקרה הזה חוק המקרקעין, הם שקובעים את הקריטריונים להגנה על זכות זו. ראו ברק, פרשנות במשפט, כרך ג', עמ' 786 ואילך. בתיקון 18 לחוק המקרקעין נקבעה מערכת של איזונים מהותיים אשר נועדה להקטין את הפגיעה בקניין שנגרמת בעטייה של בניה ברכוש המשותף. המלומד דויטש בספרו קנין, כרך א', עמ' 701 בוחן אחת לאחת אם תנאי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נשמרים בתיקון 18 לחוק המקרקעין ומוצא כי התיקון הוא תקף.

37. בע"א (חי) 1725/05 דוד נ' נברוצקי פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 3589(1)). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג' 1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

38. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה קיימת מצריכה הסכמה למצער של 3/4 מבעלי הדירות. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת.

39. הבנייה מושא ההליך כוללת, בין היתר, תוספת בניית ממ"דים, תוספת מרפסת זיזית בקומה א' ויצאה לגג בתוספת פרגולה. לכל רכיבי בנייה אלו, למעט הממ"ד, נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות אשר צמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף.

40. אין מחלוקת על כך כי הנתבעים לא המציאו הסכמות בכתב לבנייה מושא ההליך, למעט הסכמתם הם. בכתבי טענותיהם ובעדותם טענו הנתבעים כי בעלי הדירות במבנה מס' 1 לא התנגדו לבנייה מושא ההליך, וכי גם התובעות לא התנגדו באופן נחרץ לבנייה מושא ההליך, אלא ניהלו עמם משא ומתן ודרשו שינויים בתוכניות, ומשכך, בהיעדר התנגדות, יש לראותם כמסכימים לבנייה.

41. בפסיקה נקבע כי אין להסיק מהיעדר הסכמה או מיישיבה על הגדר' הסכמה פוזיטיבית. זאת יש לזכור כי עסקינן בזכויות קנייניות ששינוי בהן מחייב הסכמה ברורה, מוגדרת, חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים. ראו ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי נ"ד (3) 389 שם נקבע:

"גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

כן ראו בה"פ (מחוזי ת"א) 1266/03 הורנשטיין נ' בליצר (נבו, 25.11.2007) והפסיקה אליה הוא מפנה בפרקים 18-19 לפסק הדין.

42. בסיכומיהם טענו הנתבעים כי הבעלים של שתי הדירות במבנה 1 ביצעו "הרחבה דומה" כמשמעותה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, ועל כן יש לראותם כמסכימים, ואולם, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא הובאה ולו ראשית ראיה לבניה שביצעו בעלי דירות אלו והיקפה, ועל כן לא מצאתי לראותם כמי שנתנו הסכמה קונסטרוקטיבית כאמור בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין. ויוטעם, שלא כפי הנטען ע"י הנתבעים, על הטוען לקיומה של הסכמה קונסטרוקטיבית מכוח הרחבה דומה שביצע בעל דירה אחר להוכיח קיומה, ועליו להוכיח כי אותה בנייה של האחר אכן דומה בהיקפה ובטיבה לבניה אותה הוא מבקש ליישם ללא הסכמות מפורשות לבניה.

43. לאור האמור, ובהינתן שאין באמתחתם של הנתבעים הסכמה מפורשת של התובעות ושל שני בעלי הדירות במבנה 1, הרי שלא קיימת להם הסכמה בשיעור הנדרש על פי דין.

44. אוסיף ואטעים כי לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי לאור המשא ומתן הארוך שניהלו התובעות עמם ניתן לראות את התובעות כמי שהסכימו לבנייה או כמי שיצרו מצג של הסכמה עליו היו רשאים הנתבעים להסתמך, תוך שינוי מצבם לרעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. מחלופת המכתבים וטיוטות ההסכם שהוחלפו בין הצדדים לא עלתה בשום שלב הסכמה של התובעות לבנייה מושא ההליך. נהפוך הוא, ניכר ממסמכים אלו כי התובעות אינן נותנות הסכמה לבנייה מושא ההליך, אלא לכל היותר נכונות לשקול מתן הסכמה. התנהגותן זו שומטת את הקרקע תחת טענת הנתבעים בדבר התנגדות חסרת תום לב מצד התובעות. לו היו התובעות מבקשות להתנגד התנגדות שאינה עניינית בשם זכותן להתנגד, אזי לא היו טורחות לנהל משא ומתן עם הנתבעים ולדרוש דרישות כאלו ואחרות מהם.

וראו בעניין עדותו של פולמן ארי, בנה של תובעת 2, שהייתה אמינה עלי, בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 21.3.23 שורה 49 והמשך בעמ' 3 ממנה עלה כי התנגדותם לא הייתה דווקנית או קטגורית אלא עניינית:

"ש: זאת אומרת, עמדתן הייתה שייקוב הדין את ההר, לא תתאפשרנה תוספות בנייה לנתבעים?"

ת: ממש לא, ואפרט. אין פה התנגדות קטגורית חד משמעית בכלל, פניתם אלינו ב-2016 בתחילת 2016 ודיברתם שאתם רוצים להקים ממ"ד. אנחנו בעד ממ"דים. הצעתם לחזק את כל המבנה בתמורה לזה שתקימו ממ"ד... אחותי הסכימה באופן עקרוני, כי דיברתם רק על ממ"ד וחזוק. לאט לאט ראינו את הדברים הבאים, בתום לב ובחוסר הבנה מה עומד להתרחש עלינו... זה ממד, מרפסת מתקפלת, ירידה במדרגות אל תוך הגינה, ובגינה יש מחסן כלים, והדבר הזה עומד על 70% קירות, ויש אריחים משתלבים. זה לא הממ"ד שכולנו רצינו שיהיה לכם כי אנחנו מאמינים בממדים. הבנו שזה לא חיזוק של כל המבנה כמו שהבטחתם בהתכתבויות אסאמאס".

46. בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 20-28 העיד מר פולמן כי הגם שלא היה הרוח החיה מול הנתבעים הוא היה מעורב ומעודכן בכל שלב ושלב בממ"ד עם הנתבעים, וכי מצבה הבריאות של אחותו חייב אותו ליטול חלק בעניין ולבוא להעיד תחתיה, ושוכנעתי כי הוא מצוי בפרטים. בדיון שהתקיים הוצג לעיוני מסמך רפואי המסביר מדוע נבצר מאחותו, שניהלה מו"מ מול הנתבעים, להעיד. מסמך זה תואם את ההסבר שנתן העד פולמן בפרוטוקול מדוע נבצר ממנה להעיד.

47. וראו גם עדות הנתבע בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 21.3.23 שורות 27-32 שם מאשר הנתבע כי הם (הנתבעים) שלחו ביום 15.4.17 וביום 21.4.23 מכתבים בהם הודיעו כי כל ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים מבוטלות. וכן ראו השאלות הנוקבות שהופנו לנתבע בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 28-1 שעל מרביתן השיב הנתבע כי אינו זוכר.

48. לא מצאתי גם לקבל את טענת הנתבעים ולפיה דרישת התובעות ליתן להן "שיק פתוח" לבנייה עתידית שלהן, ולהפקיד בידיהן ערבות בנקאית על סך 500,000 ₪ המבטיחה מילוי התחייבויות הנתבעים מהווה דרישה חסרת תום לב. זאת יש לזכור, לתובעות עומדת טענה מסחרית הגיונית ולפיה, בהינתן שהנתבעים יבנו בהתאם להיתר הבנייה ישלול הדבר מהן את האפשרות לבצע חיזוק למבנה לפי תמ"א 38. בשל האמור, לא היו התובעות חייבות להסכים לבנייה מושא ההליך, ומשעה שנדרשת הסכמתן, והן אף עלולות להיפגע מהבנייה, רשאיות היו להתנות מתן ההסכמה בתנאים מסחריים שונים כמקובל בשוק החופשי. וראו בעניין דברים שנכתבו על ידי בתיק 8/156/19 כרמון נ' ויסאם (נבו, 26.3.20):

"בשים לב לכך שלנתבע מלכתחילה לא עמדה הסכמה בשיעור הדרוש - מוצאת אני לקבוע כי התנגדות התובעים בגין רצונם לשמור לעצמם את האפשרות לקדם פרויקט תמ"א 38 בבית היא לגיטימית, ואין כל משמעות לשאלת הזמן שיידרש לצורך כך לסיכוייה להצליח או להתחייבות הנתבע להרוס את הבניה בהינתן תוכנית כאמור. ויוטעם, בנייה על הגג, על אף התחייבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבע להרוס אותה, עלולה להבריח קבלנים או יזמים פוטנציאליים מלהציע הצעות או מלנסות לקדם תוכנית כאמור בבית זה, ובנסיבות תיק זה בהן הנתבע נעדר את הרוב הדרוש להתנגדות היא כדן".

49. מצאתי גם לדחות את טענת הנתבעים כי לא נדרשת להם הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית היות שהם מנצלים זכויות בנייה שאינן עולות על חלקם היחסי בזכויות הבנייה.

50. בפסיקה נקבע כי גם בניה שאינה כרוכה בניצול אחוזי בניה משותפים טעונה הסכמה. ראו את הדברים שנקבעו בע"פ 51-75 שיינר נ' נציגות הבית המשותף שד' מוריה 9 חיפה (נבו, 05.03.2019) אשר נכונים גם לענייננו:

"אין בחוק הבדל בין הרחבה של דירה שלצורך ביצועה מנוצלים אחוזי בנייה "רגילים" לבין הרחבה שלצורך ביצועה מנוצלים אחוזים שמוענקים מחמת הרצון לעודד שיפור מיגון וכו'. בנוסף, החובה שחלה על דייר בבית משותף לקבל הסכמה של חלק משאר הדיירים טרם ביצוע הרחבה של דירתו, אינה נובעת אך ורק מהטעם שהרחבה שכזו גורעת מאחוזי הבנייה, בהיבט הקנייני. המחוקק קבע את הצורך בקבלת הסכמת כל הדיירים לביצוע פעולות מסוימות, קבע כי לצרכים אחרים נדרשת רק הסכמה של 75% מהדיירים, ולגבי מקרים מסוג נוסף נדרשים 60% בלבד – אך אין בחוק אפשרות להוסיף לדירה תוספת בניה או ממ"ד בשטח של 12.5 מ"ר ללא קבלת הסכמה בכלל, אף אם על שטח המוצמד ליחידה של מי שמבקש לבצע את הבנייה.

זאת ועוד. קשה לקבל את הטענה כי בניית תוספת לצורך שיפור המיגון או בניית ממ"ד לא נכנסת אל גדרי הוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין (כי שטח שכזה "לא נספר") – וזאת שעה שסעיף 71 מתייחס במפורש בסיפא שלו לבניית ממ"דים וממ"קים. רוצה לומר, שהוראות החוק מעניקות "הקלה" לבעל דירה שמבקש להרחיב את דירתו ולהוסיף ממ"ד, בכך שנדרש רוב של 60% בלבד (ולא 75%), אך עדיין נדרשת הסכמה חלקית, וזאת לאחר שהמחוקק לקח בחשבון את תקנות חישוב השטחים, משנת 1992, אשר תוקנו לפני תיקון מס' 18, משנת 1995. בנוסף, יש לזכור כי תקנות חישוב השטחים נוגעות לפן התכנוני של בקשות לקבלת היתרי בנייה ולא בהכרח לפן הקנייני".

היקף ההסכמות הנדרש לבניית מדרגות חיצוניות, מחסן וגדרות -

51. הוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין חלה, כאמור, על הוצאה של חלקים מהרכוש המשותף לשם בנייה שמטרתה "הרחבת אותה דירה". בפסיקה התייחסו לשאלה מהי הרחבה של דירה, ואילו רכיבי בנייה לא ייחשבו כהרחבת דירה, באופן שתידרש להם הסכמה של כלל בעלי הדירות בבית.

52. ההלכה הפסוקה פירשה את המונח "הרחבה" שבסעיף 71ב לחוק המקרקעין כתוספת בנייה שמטרתה הקלה על מצוקת הדיור, אך יחד עם זאת נקבע כי נדרש כי אותה תוספת בנייה תהא בסמיכות פיזית לדירה. ראו קביעת בית המשפט ברע"א 1462-10 עטייה נ' שגיא בפסקה 19 (נבו, 02.08.2012) בעניין:

"הדרישה לסמיכות פיזית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף. זאת נוכח השיקול הפרשני הנוסף שעליו עמדנו שלפיו הכלל ביחס לדרישת הסכמת כלל הדיירים להצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נותר בעינו".

וכן נקבע בהמשך פסק הדין-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"אין לשלול את הטענה שבניית מחסן- אפילו זה אינו בסמיכות פיסית לדירה- מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות דיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף."

53. בספרות נקבע כי תנאי לכך שהבניה תיחשב הרחבה הוא שהבניה תהא מתוך דירת המבקש-

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה. . . אנכית, כגון, בנייה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. . . אופקית, כגון, בניית מרפסת או סגירתה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (איזנשטיין, עמ' 223) (ההדגשה שלי, י"ל).

54. הקמת מדרגות חיצוניות לדירה, מחסן ברגלי ממ"ד (ללא חיבור פיזי לדירה) וגדרות שתוחמות שטח מהחצר אינן ממלאות אחר תכליתו של הסעיף, הן לא נועדו להקל על מצוקת הדיור, אלא נועדו אך להקל או ליצור גישה ישירה לדירת הנתבעים ולתפוס חזקה ייחודית בשטחים מהגינה, ומשכך עבודות אלו אינן נכללות בגדר הוראות סימן ג'1 לפרק ו' לחוק המקרקעין.

וראו עדותו של נתבע 1 בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 21.3.23 שורות 8-9 שם מאשר הנתבע כי התוכנית שאושרה כוללת גדר התוחמת חלק מהחצר המשותפת. אמנם העד המשיך והעיד כי בעקבות התביעה הם הגישו תוכנית מתוקנת שאינה כוללת גדרות בחצר, אך פסק דיני יתייחס לתוכנית מושא ההליך טרם התיקונים.

55. לאור האמור, ולאור הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין הקובעת כי הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירה מסוימת בבית טעונה הסכמת כל בעלי הדירות בבית, לרכיבי בנייה אלו נדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית.

56. הנה כי כן, ברי כי לא קיימת לנתבעים הסכמת בעלי הדירות בשיעור זה לשם בניית רכיבי בנייה אלו.

57. משהגעתי למסקנה כי הנתבעים נעדרים הסכמות ברוב הדרוש, ממילא מתייתרת הכרעה בשאלה האם יש בבנייה כדי לפגוע בבית מבחינה קונסטרוקטיבית או לגרום לתובעות לפגיעה.

58. טרם סיום אציין כי התובעות ציינו באופן מפורש כי הן אינן מתנגדות לבניין ממ"ד ומרפסת זיזית בדירות הנתבעים (ראו סעיף 16 לסיכומיהן). עם זאת, לא מצאתי לאשר במסגרת ההליך בניית ממ"ד ומרפסת זיזית, שעה שלא הובאו בפני כל ראיות לכך שניתן לאשר רק שני רכיבים אלו במנותק מיתר תוכנית הבניה כפי שאושרה. ככל שניתן לאשר רכיבי בניה אלו בלבד תעמוד לנתבעים הסכמה זו.

סוף דבר-

59. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות בהתאם להיתר הבניה שקיבלו כל עוד לא תהיה באמתחתם הסכמת בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בחוק המקרקעין.

60. לעניין הוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/209/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20
Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

61. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

62. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

63. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

64. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל מצאתי לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות התובעות, יחד, בסך כולל של 11,254 ₪ לפי הפירוט שלהלן: 654 ₪ אגרת משפט, 10,000 ₪ שכר טרחת עו"ד ו-600 ₪ שכר בטלת העד פולמן. סכום זה ישולם לתובעות בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כ"ט בסיון תשפ"ג (18.6.23)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין